

1501021-09.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... tarefa. Samuel confessou a prática do tráfico desde de manhã. Fabiano disse que só acompanhava o amigo e questionado sobre estar acompanhando o Samuel, disse que era por amizade. Mas viu que Fabiano auxiliava no tráfico abordando as pessoas e indicando o Samuel, e também foi com o Samuel e com a Grabielle bater o caixa entre os carros, e ele disse isso a testemunha quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501021-09.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000730

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129991/2022 - 01º D.P. DIADEMA, 24940807 - 01º D.P.

DIADEMA, 2129991 - 01º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabiano Rodrigues Vilanova e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

SAMUEL INÁCIO DA SILVA, qualificado às fls. 08 e 34/35, FABIANO RODRIGUES VILANOVA, qualificado às fls. 07 e 40/41 e GABRYELLE CATARINA DE SENA, qualificada às fls. 09 e 27/28, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta das 13h00, na Travessa Novo Horizonte, altura do nº 30, bairro Canhema, nesta cidade de Diadema, atuando previamente ajustados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, traziam com eles e guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 55 embalagens plásticas contendo 38,0g da droga cocaína, 57 embalagens plásticas contendo 18,0g da mesma droga, na forma de crack, e 19 embalagens plásticas contendo 25,0g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls.

16/17 e laudo de constatação provisória de fls. 19/22, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva do réu Samuel, oportunidade em que foram concedidas liberdades provisórias aos corréus em audiência de custódia (fls.66/71), foram os réus notificados e citados (fls.161, 162, 165, 218/222), e apresentaram defesa preliminar as fls.127/128 e 170/175, através do então Advogado constituído do réu Fabiano, e pelo d. Defensor Público nomeado aos corréus Samuel e Gabrielly. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 10/08/2022 (fls.180/181).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente pelas Partes, com exceção da testemunha Leonardo, quem intimada, não compareceu ao forum, sendo homologada a desistência de sua inquirição, e interrogados os acusados ao final, exceto a ré Gabriele, revel, pois intimada, se fez ausente, não justificando seu não comparecimento, não estando presa. Encerrada a instrução processual sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Fabiano, inclusive, pelo tipo penal misto alternativa, não há necessidade de obtenção de lucro e pelas circunstâncias apuradas ele participou, anuiu, auxiliando materialmente no tráfico do local. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, além dos maus antecedentes de Fabiano e Gabriele, quem tem passagem na Infância e Juventude relacionado a ato infracional idêntico, e por isso afastado o benefício da redução de suas penas e fixado regime prisional fechado, além da perda do numerário apreendido.

O d. Advogado do réu Fabiano alegou que seu cliente ficou com seu amigo Thiago, bebendo, e depois foi comprar droga, e só foi preso por já ter passagem policial pelo mesmo crime, mas inexiste testemunha ocular, inexiste flagrante de venda, só a palavra dos policiais nada relevantes, até porque não viram Fabiano pegando droga ou dinheiro, havendo somente presunções em sua opinião, tanto que solto na audiência de custódia. Subsidiariamente, pede aplicação da pena base no mínimo legal, a aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Já o d. Defensor Público, pela ré revel Gabrielle, e nomeado também ao corréu Fabiano diante da renúncia de seu patrono (fl.186), reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência de Samuel com a atenuante de sua confissão, considerando ainda a confissão e a menoridade relativa de Gabrielle a reduzir sua pena, e diminuída, por se tratar de tráfico eventual a ambos os acusados, com a substituição com fulcro no art. 44 do CP para a ré, fixando-se regime aberto a ambos os acusados, até pela detração penal, e possibilidade dos acusados recorrerem em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no IP de fl.01, auto de exibição e apreensão de fls.16/17, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls.19/22 e 135/136), ambos positivos para a cocaína.

A autoria é incontestada não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente,

como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.02/05), dando cumprimento à operação "Sufoco", com o fito de combater e prevenir delitos nesse Município, incluindo o tráfico de drogas, se dirigiram até a Travessa Novo Horizonte, Jd Canhema, local conhecido pelo comércio de drogas. Lá, se utilizando de viatura descaracterizada, deram início a uma campanha, que consistia em observar a compra e venda de drogas. Muito próximos do ponto de vendas e sem serem notados, puderam observar que no local se encontravam dois homens, posteriormente identificados como Samuel Inácio da Silva (trajando camiseta branca) e Fabiano Rodrigues Vilanova (trajando blusa vinho). Visualizaram transeuntes se aproximando do ponto de venda de drogas, sendo que estes primeiro conversavam e eram orientados por Fabiano, pessoa que organizava o atendimento dos usuários. Em seguida, os compradores iam na direção de Samuel, que, portando uma pochete de cor de rosa, recolhia o dinheiro e entregava as drogas aos usuários. Passados alguns instantes, surgiu no local uma mulher, posteriormente identificada como Gabryelle Catarina de Sena, que, ao se aproximar de Samuel e Fabiano, indagou a eles: "vamos bater o caixa aqui atrás dos carros." Ato contínuo, todos os três deram início à contagem de drogas e dinheiro. Logo em seguida, chegou o usuário Leonardo Trevejo Feitosa da Silva, com R\$ 20,00 em mãos, restando ele solicitado a aguardar. Diante do exposto, tendo em vista a distração dos suspeitos, decidiram agir, desembarcando da viatura e logrando realizar a captura de todos eles. No momento da abordagem, Samuel portava uma pochete, de cor rosa, que continha 35 invólucros de cocaína; 57 pedras de crack e 19 invólucros de maconha. No bolso de Samuel, fora apreendida a quantia de R\$ 46,00, em notas de R\$ 2,00. Gabryelle fora flagrada segurando uma sacola preta, que tinha em seu interior uma bolsa vermelha. Dentro da sacola havia a quantia de R\$ 75,00. Já no interior da bolsa vermelha, localizaram 20 invólucros de cocaína. E poder de Leonardo, localizaram R\$ 20,00. Ante o exposto, conduziram todos para essa unidade policial.

Sob o crivo do contraditório o policial Elvis Leonardo Gomes respondeu, que era dia de operação. O local é conhecido como ponto de tráfico. Fizeram campanha. Samuel estava com uma pochete e o outro seria o campana. Viu usuário chegar neles e ouviu o que eles diziam. Fabiano questionava o que queriam adquirir e via se não era policial, e indicava o Samuel, quem entregava a droga. Daí chegou a ré com uma sacola preta e disse para se posicionarem entre os caixas para baterem o caixa. Nisso chegou Leonardo, usuário, pedindo droga, mas pediram para ele aguardar porque estavam batendo o caixa. Aproveitaram para fazer a abordagem. Com Leonardo tinha o dinheiro para comprar maconha, como ele confirmou. Fabiano disse que estava com amigo e que não estava fazendo nada. Com samule estavam as drogas e com Gabriele também tinha cocaína e dinheiro treocado. Gabriele confessou que a gerente pediu para ela fazer essa tarefa. Samuel confessou a prática do tráfico desde de manhã. Fabiano disse que só acompanhava o amigo e questionado sobre estar acompanhando o Samuel, disse que era por amizade. Mas viu que Fabiano auxiliava no tráfico abordando as pessoas e indicando o Samuel, e também foi com o Samuel e com a Grabielle bater o caixa entre os carros, e ele disse isso a testemunha quando ela pediu para comprar droga, que era para esperar que estavam batendo o caixa.

Igualmente o policial Mauro Senhorini alegou que tinha Operação Sufoco. O local já é conhecido como ponto de venda. Foram com viatura descaracterizada. Ficaram observando por uns quinze minutos. Viram dois rapazes comprarem com eles. Daí chegou uma moça com uma sacola preta e chamou os dois réus. Conferiu as drogas e foi pegar o dinheiro. Nisso veio um outro rapaz comprar droga e foram no embalo. Eles mandaram esperar porque iam bater o caixa. O abordaram. O Fabiano era o campana e Samuel estava com a sacola contendo as drogas além da quantia em dinheiro, e a Gabryelle estava com uma sacola preta com uma bolsinha vermelha com mais drogas. Todos foram presos e encaminhado Leonardo como testemunha, pois ele disse que ia compra-las. Reconhece os réus, e a moça é baixinha, branca, cheia de

tatuagem. Foi a primeira vez que os viu no local. Todos confessaram. Gabryelle disse que foi fazer um favor para uma amiga. Samuel confessou. Fabiano veio com uma desculpa que estava lá com o amigo após voltar de uma balada, mas viu que a pessoa ia até ele e era ele quem indicava o Samuel ao comprador. Às reperguntas, disse que Fabiano indicava o Samuel, ele era o campana, quem avisava se vinha polícia inclusive.

A testemunha Leonardo Feitosa da Silva, em solo policial (fl.06) disse que é usuário de maconha e, na data de hoje, decidiu ir até a "boca de fumo" localizado no sítio do fato. Contudo, assim que lá chegou, não conseguiu prontamente adquirir a drogas, haja vista que Samuel, Fabiano pediram para aguardar. Em seguida, surgiu Gabryelle indagando aos dois referidos sobre a contabilidade da droga. Antes que pudesse adquirir quatro porções de maconha, a Polícia Civil chegou, restando todos abordados. Questionado, afirmou que Samuel era quem trazia as drogas consigo, enquanto Fabiano permanecia ao lado dele, observando o movimento ao redor. Em juízo, essa testemunha não foi ouvida, dado que ausente, embora intimada, tendo as Partes desistido de sua inquirição, o que foi homologado.

A testemunha de defesa Thiago Teixeira não presenciou os fatos. Fabiano estava jogando bilhar perto de sua casa até por volta da meia noite quando foi embora, mas ele ficou jogando e bebendo cerveja. No dia seguinte, de manhã, soube que ele foi abordado pelos policiais. O réu trabalha como autônomo prestando serviços para uma empresa. Era um dia de semana. Sabe que o réu já foi abordado antes por uso de droga, cocaína. O réu Fabiano é divorciado e tem um casal de filho.

Os réus, em solo policial (fls.07/09) preferiram calar-se.

Em juízo, o acusado Samuel O acusado Samuel confessou que estava usando droga, fez tratamento ano passado, mas voltou a usar e sentiu abstinência, usou droga, cocaína, mas como não tinha tanto dinheiro, um menino perguntou se não queria ficar lá até o outro menino chegar, e ficou. Mora na Pauliceia e a biqueira mais próxima é a do local dos fatos. Estava desde às onze da manhã quando o menino passou as coisas para ele até o menino chegar. Durou cerca de uma hora e meia a duas horas até ser preso. Chegou um menino para comprar uma pedra e ele percebeu que estava tremendo, e perguntou se ele não servia pra isso era melhor não pegar, mas ainda assim serviu ele, e ficou mais um tempo. Daí chegou a menina, a Gabryelle, que queria o dinheiro que tinha feito, e não sabe se ela estava com mais drogas. Ela perguntou quanto ele já tinha feito, e estava fazendo a conta do dinheiro, foi tirando dos bolsos, colocando no chão. Nisso chegaram os policiais. Fabiano é amigo seu, e ficou lá. Ele foi comprar droga. Tinham se encontrado antes, tinham consumindo droga, e depois se encontraram na biqueira. Trocou o dinheiro dele para pegar o dinheiro em mãos e voltou para comprarem mais drogas. Estava com Fabiano, na biqueira, e como usam a mesma droga, se encontraram na biqueira, usaram uma cocaína, e daí o menino perguntou se ele estava à toa e se não queria ficar lá, e aceitou, e Fabiano ficou lá também.

O corréu Fabiano O réu Fabiano disse que na noite anterior estava jogando e bebendo num bar até por volta da meia noite, quanto Thiago foi embora, mas permaneceu bebendo. As horas foram passando e foi até o ponto de droga buscar uma droga. Não tem noção do horário porque tinha bebido bastantes. Ao chegar no local, na viela, foi abordado pelos policiais que já tinham pego duas pessoas, um rapaz e uma menina, os corréus. Só estava com dinheiro e por já ter passagem por tráfico, falaram que estava no meio, e o levaram ao DP, mas nega ter envolvimento com o tráfico. Ficou parado, em pé, vendo se via alguém. Não notou os policiais se aproximando de si, e nisso já foi abordado.

A acusada Gabryelle não foi ouvida sob o crivo do contraditório, pois embora intimada pessoalmente, não compareceu ao Fórum nem se fez presente via Teams, nem justificou sua ausência, não se encontrando presa, de modo que decretada sua

revelia.

Logo, a confissão judicial do réu Samuel e a extrajudicial da acusada Grabryelle estão em consonância entre si e com o contexto probatório, principalmente pelos testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, porque embora o corréu Fabiano não tenha confessado os fatos, optou pelo silêncio em solo policial, oportunidade em que já deveria ter trazido a mesma versão dita em juízo, depois que teve tempo e condições de amadurecer versão mais satisfatória aos interesses da Defesa, mas se verdadeira é, o normal seria ele já ter trazido a mesma versão desde sede o início, de que não conhecia os corréu e que estava no local apenas para comprar drogas, retornando da noite em que passou bebendo e jogando sinuca, sendo preso por já ter passagem policial. Contudo, nem é crível que alguém que se diz trabalhador, como a testemunha de defesa do réu Fabiano tentou fazer crer, fique até de madrugada bebendo e jogando sinuca numa quinta feira, até de madrugada, e depois vá até uma biqueira comprar cocaína para seu consumo, e ali fique até por volta de uma hora da tarde só para isso. E o seu trabalho, que horas compareceria? Ora, a aludida testemunha disse ter ficado na companhia do referido réu até por volta da meia noite. A prisão se deu no dia seguinte, em torno das 13:00 horas. O réu não provou que estivesse sob o efeito de álcool e cocaína. Pelo contrário, ele conseguiu sair do bar onde disse que estivera, ter ido até a biqueira para comprar droga, alegando ter sido preso antes disso, e que os policiais já haviam detido os outros dois corréus. Entretanto, ele foi desmentido pelo acusado Samuel, quem sempre afirmou que são amigos e que Fabiano estava lá consigo, embora estivesse com dinheiro que pegou para ele no cartão dele, e que Fabiano não pretenderia receber nada por lhe auxiliar, mas tal fato além de ser risível, não encontra eco nos relatos dos policiais que afirmaram terem visto Fabiano junto com Samuel, e ouviram aquele perguntar a mais de um usuário qual droga queriam, e indicar o Samuel, quem efetivamente entregou a droga ao comprador, além de terem visto Fabiano acompanhar Samuel e Grabryelle até uns veículos, onde ficaram checando o dinheiro e recebendo mais drogas, tanto que foi Fabiano quem mandou o usuário Leonardo esperar um pouco para ser servido, porque estavam "batendo o caixa". Portanto, Fabiano participou ativa e efetivamente no crime de tráfico de drogas, ainda que eventualmente não visasse lucro pessoal, o que não se exige por lei.

Assim, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar e trazer consigo, condutas perpetradas pelos réus, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

No mais, não se alegue haver somente o relato dos policiais a embasar a condenação, pois como visto, os réus Samuel e Gabryelle também confessaram os fatos e houve a delação, além das demais provas, como visto. Ressalto, ainda, o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Não bastasse isso, os policiais sempre afirmaram que o réu Fabiano era quem recepcionava os usuários e os encaminhava ao corréu Samuel, quem efetivamente entregava as drogas, sendo que posteriormente surgiu a corré Gabryelle para acercar o caixa e em seu poder também haviam drogas e dinheiro, sendo tudo isso presenciado pelos dois policiais e pela testemunha civil presencial Leonardo Feitosa, quem afirmou que os dois réus do sexo masculino pediram para esperar para acertarem o

caixa com Gabryelle, que chegou depois, tudo sem prova contrária. Ainda tenham os réus alegado serem consumidores de maconha, o que só foi confirmado com relação ao réu Fabiano através de sua testemunha de Defesa, sem prova do alegado por parte do réu Samuel, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. Neste sentido: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (134 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), a apreensão de numerário proveniente das vendas de drogas (fls.16/17) são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável. Ainda que se trate de agente que se diz usuário, situações que não se opõe, e sim coexistem.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (131 no total) o que reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, e os maus antecedentes criminais de Fabiano (fl. 51 – condenação definitiva por tráfico nessa Segunda Vara Criminal de Diadema há mais de cinco anos, não mais considerado reincidência, mas sim maus antecedentes) fixo em primeira fase, as penas base acima do mínimo legal para todos os acusados, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para Gabryelle e Samuel, e em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa para Fabiano, considerado seus maus antecedentes também.

Fixo cada dia multa, por réu, em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira deles.

Em segunda fase, ausente circunstâncias agravantes a réu Gabryelle, mas presente a atenuante da confissão da acusada, relativamente menor inclusive, e ainda que a confissão tenha sido informal apenas, dado que revel, não a confirmou em juízo, mas tão pouco há negativa de autoria, e como me vali dessa para também embasar a condenação, ora a considero a atenuar a pena também pela menoridade relativa, ao mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

E não havendo circunstâncias agravantes nem atenuantes em favor de Fabiano, resta sua pena inalterada nessa etapa (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Sendo o corréu Samuel reincidente específico (fl. 47 – condenação proferida por essa Segunda Vara Criminal de Diadema), agravo a pena em 1/6, alcançando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão mais 680 dias-multa.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, a nenhum dos réus. Isso porque Gabryelle e Fabiano já tem passagens policiais por crime análogo e persistiram no crime a indicar maior dedicação e integração de organização criminosa, não apenas pela reiteração, mas por estarem juntos, dividindo tarefas, trabalhando em conjunto, pois enquanto Gabryelle fazia o abastecer e conferia o caixa, Fabiano recebia os compradores, perguntava o que queriam, os encaminhava a Samuel, e também fazia a segurança e vigília do local, para que Samuel guardasse e entregasse as drogas.

Samuel, por seu turno, reincidente específico, há ainda expressa vedação legal. Portanto, inaplicável a ele a benesse. Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência do réu Samuel e a grande quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado. E aos demais acusados, fixo o regime prisional semiaberto, considerando a grande quantidade da pena, e a preponderância da natureza e da quantidade das drogas, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Fixo o regime prisional fechado ao réu reincidente Samuel, e o semi aberto aos réus primários Gabryelle e Fabiano, principalmente pela grande quantidade e variedade das drogas. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo (agente não é primário) a Samuel. E quanto aos demais acusados, não se mostra socialmente recomendável a Fabiano, quem conta com antecedentes pelo mesmo crime, e à Gabryelle, revel inclusive, o que indica que não cumpriria comeventual pena restritiva de direitos, dado que seu ultimo comparecimento ao forum foi há dois meses e não se fez presente na audiência, ainda que virtualmente, o que poderia ter feito de sua própria casa ou trabalho, não justificando mais benesses que a soltura já lhes conferida.

Ademais: " Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime." (TJAP) RT 772/617. Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e em que pese a

Custodiado no curso do processo, o Condenado Samuel não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

E deixo de me manifestar sobre a detração penal de Samuel parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso

contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de cinco meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Com relação aos réus Gabryelle e Fabiano, permito o recurso em liberdade ao último por estar solto no decorrer da instrução processual, e por ter comparecido a todos os atos processuais, valendo-me do princípio da presunção de inocência. Mas com relação a acusada Gabryelle, revel, vedo a possibilidade de recorrer em liberdade, pois solta em audiência de custódia, não comparece ao fórum há dois meses, e intimada pessoalmente, não se fez presente presencial nem virtualmente a audiência, não justificou sua ausência, descumprindo assim as condições de sua soltura, de modo que para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, não lhe será dado o benefício de prosseguir solta caso pretenda recorrer.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra SAMUEL INÁCIO DA SILVA, qualificado às fls. 08 e 34/35, FABIANO RODRIGUES VILANOVA, qualificado às fls. 07 e 40/41 e GABRYELLE CATARINA DE SENA, qualificada às fls. 09 e 27/28 como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e o faço para condenar o primeiro à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 680 dias-multa. Condeno o segundo à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. E condeno a última à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

Fixo cada dia-multa, por réu, em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido à data do efetivo pagamento.

O condenado Samuel não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. A ré Gabryelle não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário. Permito ao réu Fabiano o recurso em liberdade.

Sendo os réus Samuel e Gabryelle assistidos pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora. E condeno o corréu Fabiano ao pagamento das custas processuais, em 100 Ufesp, ante a constituição de Advogado particular.

Decreto a perda de bens apreendidos (fl.16/17), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de objetos e a incineração de drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se

e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

P.I.C.

Diadema, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA